

1500358-20.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas.

De mais a mais, cumpre enfatizar que a Lei nº 13.964/2019 não afastou a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes e não se trata de tipos penais distintos aqueles previstos no artigo 33, caput e § 4º, da Lei de Drogas. Nesse sentido:

"O tráfico de entorpecentes é o grande mal da sociedade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500358-20.2021.8.26.0594

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO JUNIOR MARTINS DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marina Freire

Vistos.

O réu foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, sendo condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme r. sentença de fls. 211/219.

O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da Defesa e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para fixar a pena-base do réu em 1/4 acima do mínimo legal, sem reflexo na pena final aplicada, mantida no mais a sentença então guerreada.

Conforme certidão de trânsito em julgado de fls. 373, o referido acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 29.10.2021 e para o réu em 05.11.2021.

Baixados os autos para cumprimento do acórdão confirmatório da sentença condenatória, aportou ofício oriundo do Superior Tribunal de Justiça dando conta de que foi impetrado habeas corpus naquele egrégio sodalício, de nº 699202/SP.

A decisão proferida em sede de habeas corpus pelo c. Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada (fls. 407/413).

Assim, foi determinado ao Juízo de primeiro grau que refizesse a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, o regime inicial adequado à nova pena fixada, e a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos.

Destarte, refaço o tópico referente à dosimetria da pena (fls. 217/219), EXCLUSIVAMENTE DIANTE DA ORDEM DO E. STJ, para constar:

"Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, resta somente a fixação da pena.

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito lhes são desfavoráveis, haja vista a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (24,54 g do entorpecente conhecido como cocaína, dividido em 118 porções, 35,03 g do entorpecente conhecido como crack, dividido em 53 porções e 106,03 g do entorpecente conhecido como maconha, dividido em 189 porções).

Destarte, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do delito), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/4, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, consoante o estabelecido no v. Acórdão de fls. 340/352.

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, segundo a Súmula nº 231 do STJ, nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, de sorte que a sanção fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, em que pese o entendimento dessa magistrada de que as circunstâncias concretas formam quadro fático probatório para concluir pela dedicação do réu à atividade criminosa do tráfico e, de consequente, impedir a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mister o reconhecimento da minorante em questão, em atenção à decisão superior. Dessa forma, a pena deverá ser reduzida em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa).

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime aberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas.

De mais a mais, cumpre enfatizar que a Lei nº 13.964/2019 não afastou a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes e não se trata de tipos penais distintos aqueles previstos no artigo 33, caput e § 4º, da Lei de Drogas. Nesse sentido:

"O tráfico de entorpecentes é o grande mal da sociedade contemporânea, que faz adoecer, de forma grave e muitas vezes irreversível, parte expressiva da população, instiga e propicia a prática de vários outros delitos, até mais graves, vítima a juventude e prejudica o seu desenvolvimento, desagrega as famílias e os relacionamentos e multiplica a indigência. Atuação como a do acusado coloca em perigo grande número de consumidores, e torna acessível droga de efeitos extremamente deletérios a pessoas que a ela não teriam alcance se encontrassem maior dificuldade em sua aquisição. Justificada a imposição, ao menos de início, do regime fechado, com vistas ao cumprimento das finalidades preventiva e retributiva da pena. [...] Incabível, ainda, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes hediondos ou equiparados, observando-se que o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não define um tipo penal distinto do artigo 33, mas tão somente estabelece uma causa especial de redução de pena do mesmo crime de tráfico de entorpecentes. Neste ponto, ressalto que a recente Lei nº 13.964/2019 não alterou a natureza hedionda do crime do parágrafo 4º do artigo 33 da lei em comento. A única ressalva que fez para que tal delito não seja considerado como hediondo foi "para os fins deste artigo", referindo-se, exclusivamente, ao artigo 112 da LEP, que trata dos requisitos para a progressão de regime de pena (art. 4º, Lei nº 13.964/19). Ou seja, a nova lei limitou-se, em um parágrafo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a reduzir o prazo para progressão nos crimes de tráfico com redutor, mas não o excluiu da tipificação como equiparado a hediondo, já que, embora na mesma oportunidade e pelo mesmo diploma legal tenha feito alterações na Lei nº 8.072/90 (Lei que define os crimes hediondos e equiparados e disciplina seu tratamento diferenciado), não alterou o artigo 2º desta, que equipara o tráfico de entorpecente (independente de ser na forma simples, com aumento ou com redução de pena) aos hediondos. Urge salientar que o legislador, ao elaborar o vulgarmente denominado "Pacote Anticrime", promoveu alterações em inúmeras legislações, inclusive naquela que define o crime hediondo ou equiparado e, embora podendo definir nesta lei a exclusão do tráfico com o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não o fez. Optou, apenas e tão somente e, de forma expressa, a tratar esta modalidade de tráfico de forma não equiparada a hediondo para fins do artigo 112 da LEP, ou seja, em relação ao prazo para progressão de regime. Há de se ressaltar ainda que a natureza e gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes, acima destacados, impedem a aplicação das penas alternativas. Além da frontal incompatibilidade com o regime prisional adequado (inicial fechado), não se reconhecem como preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, na medida em que se evidencia insuficiente à prevenção e repressão do delito a substituição punitiva e suspensão da pena à vista do grau de reprovabilidade da conduta." (TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 1500179-57.2019.8.26.0594. Relatora: Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti. Data do julgamento: 28 de novembro de 2019) (destaquei)

Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso in concreto. Assim, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado.

Ainda, deixo de analisar o disposto no art. 387, § 2º, do Código Processo Penal, pois o cumprimento da pena é apenas um dos requisitos para progressão de regime, sendo, igualmente, necessária a análise dos requisitos subjetivos, a exemplo da boa conduta carcerária. Desse modo, eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo das execuções criminais.

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que a imposição da penalidade corporal ainda se faz necessária diante da gravidade do delito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu PAULO JUNIOR MARTINS DE LIMA à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época da infração para cada dia-multa, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado”.

Mantido o regime fechado, permanecem presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar. Expeça-se, pois, ofício de recomendação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA